

1500207-31.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... as denúncias indicavam a prática de tráfico pelo acusado, bem como que a droga comercializada pertencia ao Valdomiro, vulgo Mirinho. Sustentou que Márcio negou a prática do tráfico, mas após ser dada a voz de prisão pediu para sua esposa comunicar o Mirinho sobre a sua prisão. Contou que presenciou Márcio entregando o entorpecente defronte a sua residência. Após abordar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500207-31.2022.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-31.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO DA SILVA LISBOA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500207-31.2022.8.26.0558

Vistos.

MÁRCIO DA SILVA LISBOA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo(s) 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 16 de abril de 2022, por volta das 17h24min., na Avenida Joaquim Sampaio, 591, centro, no município de Sales e Comarca de Urupês, o denunciado vendeu uma porção de cocaína, com peso aproximado de 4,2 gramas, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros. A denúncia teve por base o inquérito policial e foi recebida no dia 13 de maio de 2022 (fl. 108).

O réu foi citado (fl. 124) e apresentou resposta à acusação (fls. 271/280), que foi devidamente apreciada (fl. 287).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez (fls. 379/391), pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

Quanto ao mérito, iniciando as necessárias perquirições pela imputação referente à prática do tráfico, observo, nesse particular, que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo de constatação (fl. 10), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 95/97), bem como pela prova oral colhida. A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Guilherme Garbuio, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento, quando visualizaram Márcio entregando algo para George. Disse que não realizaram a abordagem defronte a residência do acusado, pois haviam várias pessoas no local, porém acompanharam George e realizaram a abordagem logo em seguida. Afirmou que George, inicialmente, desobedeceu a ordem de parada e parou a bicicleta próximo de sua residência. Durante o acompanhamento, o declarante viu que George colocou algo em sua boca. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém George estava com dificuldade para falar. Dentro da boca de George foi encontrada uma porção aparentando ser cocaína. Ato contínuo, os policiais retornaram até a residência de Márcio e realizaram a abordagem do acusado. Em revista pessoal, com o réu nada de ilícito foi encontrado, contudo, diante de todo o contexto foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao plantão policial. Informou que o réu era conhecido nos meios policiais, pois haviam diversas denúncias em seu desfavor, bem como em razão de seu envolvimento em ocorrências anteriores. Afirmou que as denúncias indicavam a prática de tráfico pelo acusado, bem como que a droga comercializada pertencia ao Valdomiro, vulgo Mirinho. Sustentou que Márcio negou a prática do tráfico, mas após ser dada a voz de prisão pediu para sua esposa comunicar o Mirinho sobre a sua prisão. Contou que presenciou Márcio entregando o entorpecente defronte a sua residência. Após abordar o comprador, ele declarou que havia adquirido a droga do réu, bem como que não era a primeira vez que havia adquirido drogas de Márcio.

A testemunha Renato Adnan Malcherte, policial militar, contou que estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu entregando algo à George e, logo em seguida, o comprador deixou o local utilizando uma bicicleta. Disse que houve um breve acompanhamento e visualizaram o indivíduo colocando algo em sua boca durante o deslocamento. Afirmou que foi realizada a abordagem de George e, em revista pessoal, dentro de sua boca, foi encontrada uma porção de cocaína. Indagado, ele disse que havia comprado a porção de cocaína de Márcio, além de informar que já havia comprado drogas do acusado anteriormente. Confirmou que visualizou a entrega do entorpecente pelo acusado e manteve o contato visual com o comprador até a abordagem. Contou que haviam denúncias em desfavor do acusado, indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo

valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0094524-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016);

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

George Jean Ferreira, ouvido na condição de informante, afirmou que foi "comprar" na residência do acusado, vulgo Barrão, e, ao sair do local, foi abordado pelos policiais. Disse que já havia comprado do acusado em outra oportunidade e, na data dos fatos, era a segunda vez. Sustentou que tinha o conhecimento que o réu traficava há mais de um ano.

O réu, interrogado em juízo, confessou que vendeu uma porção de cocaína para George na data dos fatos.

Logo, não há dúvidas que o réu fora efetivamente surpreendido logo após vender uma porção de cocaína, conduta que se amolda ao tipo imputado.

A confissão do acusado foi corroborada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente, o depoimento de George e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência. .

De seu turno, a prova coligida também evidencia o intuito mercantil, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Nesse particular, destaco que a diligência policial que culminou com o ajuizamento desta ação penal não se deu ao acaso, decorrendo de inúmeras denúncias alusivas à prática do tráfico pelo acusado, elementos de prova indiciários confirmados pela apreensão com usuário, logo após a venda efetuada pelo acusado.

A posse de numerário sem prova de desempenho de atividade lícita remunerada também evidencia o tráfico.

Por fim, as condições pessoais do increpado também amparam a pretensão punitiva estatal na forma como manejada, pois observa-se que o réu ostenta condenação definitiva (fl.44) pela prática de crime coetâneo.

De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que muitos usuários acabam praticando o comércio espúrio para viabilizar a manutenção do próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).

Encerrando a tipificação, sublinho que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra aplicável na espécie, já que o réu é multirreincidente, conforme demonstra, exemplificativamente, a certidão cartorária de fls. 40/45.

Desse modo, apreciadas as teses levantadas por acusação e defesa, não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a procedência dos pedidos formulados, com a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, verifica-se que o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 41/44, processos nº 0000322-07.2009.8.26.0648 e 1500130-14.2020.8.26.0648). Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), bem como a agravante da multirreincidentia (art. 61, I, do Código Penal), firmada com base na certidão de fls. 40/45 (processos nº 0001097-75.2016.8.26.0648 e 0000034-78.2017.8.26.0648).

Alterando entendimento anteriormente encampado, passo a reputar viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois a atenuante pode refletir aspecto positivo sobre a personalidade do agente, caracterizando circunstância preponderante em relação à reincidência, consoante dicção do artigo 67, do Código Penal.

No entanto, no caso dos autos, não se trata de simples reincidência, uma vez que o réu é multirreincidente e, portanto, a agravante deve preponderar sobre a circunstância atenuante.

Recentemente a questão foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se firmou posição consonante com a ora adotada.

Veja-se:

Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidentia, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.

Assim, feitas tais considerações, compenso parcialmente a circunstância agravante com a circunstância atenuante e, considerando a preponderância da multirreincidentia, majoro a pena em 1/6 obtendo o total de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Nada há a ser considerado na terceira etapa, valendo registrar que os antecedentes e a reincidência do acusado afastam a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o reconhecimento do privilégio exige, dentre

outros requisitos, que o agente seja primário e de bons antecedentes.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Sem confrontar posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, reputo inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a substituição condicional da pena, considerada a inteligência dos artigos 44, II e III e 77, I e II, ambos do Código Penal.

Tratando-se de pena de reclusão aplicada a réu reincidente, o artigo 33, do Código Penal, também exige a imposição de regime inicial fechado de cumprimento.

Destaco, encerrando, que a regra constante da nova redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, não conduzirá à alteração do regime inicial de cumprimento, fixado em função da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não do montante da reprimenda corporal, cumprindo anotar que a regra em testilha não autoriza o juízo do conhecimento a realizar progressão de regime, atribuição exclusiva do juízo das execuções (artigo 66, III, "a", da Lei 7.210/84).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar MÁRCIO DA SILVA LISBOA, portador da cédula de identidade R.G. nº 40.297.237/SP, filho de Juvenal da Silva Lisboa e Maria de Lourdes Teixeira Lisboa, natural de Sales, estado de São Paulo, devidamente qualificado nos autos (fls. 18 e 20), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão em regime inicial fechado e e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto, à luz da nova redação dada ao artigo 313, do Código de Processo Penal, pela Lei 12.403/2011, impõe-se a manutenção da prisão, ficando agora reiterados os fundamentos expostos na r. decisão de fls. 54/57, do apenso, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em acréscimo, não se pode ignorar que deverá o increpado iniciar o cumprimento de sua pena corporal em regime fechado, de modo que sua libertação nesse momento processual seguramente comprometeria a aplicação da Lei Penal. Além do mais, verifica-se que o réu é multirreincidente o que denota que, em liberdade, voltará a praticar novas infrações penais graves, de modo que as cautelares distintas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Caso haja recurso de qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisório, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Restando evidente o nexo etiológico entre o numerário constrito nos autos (fl. 09) e a prática do tráfico, não tendo o réu logrado demonstrar a origem lícita do dinheiro, com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "b", do Código Penal, decreto sua perda em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), ficando concedido ao réu o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os

efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA